KINX1992006792

【特別法判例評釋】

勤勞者에게 不利益한 就業規則變更의 要件

辯護士 崔 明 圭

* 事件의 表示 (大法院 1991. 4. 9. 宣告, 90다 16245號 判決 "損害賠償"〈法院公報 897號 22面〉)

一. 序

就業規則에서 勤勞條件에 대해 勞動者에게 不利한 條項을 新設하거나 既存의 條項을 不利益하게 變更하는 경우에 이를 특히 不利益 變更이라 하며, 例를 들어 退職金에 관한 規則을 變更하여 支給基準을 낮추거나 停年退職制를 新設하는 경우 등이 이에 該當한다고 할 수 있다.

우리 나라 勤勞基準法 第95條 1項에서 「就業規則의 作成 또는 變更에 관하여 當該 事業場에 勤勞者의 過半數로 組織된 勞動組合이 있는 경우에는 勞動組合, 勤勞者의 過半數로 組織된 勞動組合이 없는 경우에는 勤勞者의 過半數의 意見을 들어야 한다. 다만, 就業規則을 勤勞者에게 不利益하게 變更하는 경우에는 그 同意를 얻어야 한다」라고 規定되어 있는데, 우리 大法院은 1977. 7. 26. 宣告 77다 355 判決에서 「就業規則의 變更에 대해 既存 就業規則의 適用을 받고 있던 勤勞者集團의 集團的 意思決定方法에 의한 同意를 要한다 할 것이며, 그 同意方法은 勤勞者 過半數로 組織된 勞動組合이 없는 경우에는 勤勞者들의 會議 方式에 의한 過半數의 同意가 없는 限 就業規則의 變更으로서의 效力을 가질 수

없고, 따라서 그러한 就業規則變更에 대하여 個人的으로 同意한 勤勞者에 대해서도 效力이 없는 것이다」라고 하여 「就業規則의 不利益 變更에는 勤勞者의 集團的 同意를 必要로 한다」는 原則을 定立하였고 以後 判決의 대부분이 위 判決을 受容하고 있다.

그런데, 大法院 1991. 4. 9. 宣告 90다 16245 判決에서는 「勤勞基準法 第94條, 第95條에 의하면 使用者가 就業規則을 作成함에 있어 當該 事業場 勤勞者의 過半數의 意見을 들어야 하며, 就業規則을 勤勞者에게 不利益하게 變更하는 경우에는 그 同意를 얻어야 하고 그 同意를 얻지 못한 경우에는 勤勞者에게 不利益하게 變更되는 部分은 無效라 할 것이나, 애초에 就業規則을 作成함에 있어 勤勞者의 過半數의 意見을 듣지 아니하거나 그 同意를 얻지 아니하였다 하더라도 그 就業規則의 內容이 勤勞基準法에 違反하지 않는 限 그 就業規則이 全部 無效가 되는 것은 아니다」.

또한, 「停年規則은 當該 事業場에 있어 勤勞者가 提供하는 勤勞의 性質, 內容, 勤務形態 등 諸般 與件에 따라 合理的인 基準을 둔다면 같은 事業場內에서도 職責 또는 職級에 따라 서로 차이가 있을 수 있는 것이고, 이같은 基準에 따라 會社가 定한 停年規定이 日傭勞動者의 稼動年限이나 公務員 및 同種會社 職員의 停年보다 다소 下廻한다고 하여 이를 法律上 無效라 할 수 없다」라고 하고 있는데 위의 두가지 判例의 立場을 어떻게 받아 들어야 할 것인가가 問題이다.

특히, 不利益 變更의 問題는 就業規則의 本質을 어떻게 把握하는가 하는 點과 理論的으로 깊이 關聯되어 있어 學說上의 對立이 심한 部分이다.

원래, 勤勞者의 同意를 要求하는 것은 就業規則을 契約이라고 보는 說의 立場인데 우리 判例는 就業規則을 規範이라고 보는 說(授權說)을 取하면서도 다른 한편으로 勤勞者 集團의 同意를 要求하는 點이 特異한 點이라 할 수 있다.

以下에서 不利益 變更에 대하여 勤勞者의 同意가 必要한 것인가, 必要로 한다면 그 同意의 方式은 어떤 것이어야 하는가, 만일 勤勞者의 同意를 얻지 못했다하여도 使用者가 作成變更한 就業規則이 合理的이라면

그것은 有效라 할 수 있는가 등에 대한 判例의 立場을 살펴보고 그러한 判例의 妥當性을 批判 檢討해 보기로 한다.

二. 就業規則과 勤勞契約

1. 就業規則의 意義

就業規則이란 使用者가 多數의 個別的 勤勞關係의 處理上의 便宜를 위하여 勤勞契約의 內容이 되는 事項과 服務規程 및 職務秩序에 관한 事項을 一方的으로 定하는 것으로서 普通契約約款(Allgemeine Geschafts bedingungen)과 法律上 本質이 다른 것이 없다.

그러므로, 그것은 이른바 附合契約(Contrat d'ad hesion)의 一種으로 市民社會에서 널리 利用되고 있는 法的 技術을 使用者가 勤勞契約 關係에 대하여 利用하고 있는 것이다.

이에 대하여 法律的 考察을 함에는 勤勞者의 利益을 保護한다는 見地에서 解釋하고 또 立法的 措置를 講究해야 할 것이다.

2. 就業規則에 대한 國家的 監督

勤勞者는 事實上 經濟的, 社會的 從屬性으로 인해 就業規則의 一般的 適用에 반대할 수 없다는 現實을 考慮하여 國家는 就業規則에 대한 監督措置를 勤勞基準法에 規定하고 있다.

즉, 第94條에서 就業規則의 作成과 申告義務를 賦課하고 第95條에서 그의 變更, 作成 등에 있어서 勤勞者 過半數의 意見聽取 또는 勞動組合의 意見聽取를 義務化 하며, 第97條에서는 團體協約이 就業規則에 優先함을 規定하고 있다.

3. 就業規則의 變更과 勤勞契約

就業規則은 使用者가 一方的으로 定하는 것이므로 이를 變更함에 있어서도 使用者가 一方的으로 變更할 수 있다.

그러나 變更前에 이미 勤勞契約을 締結하고 있는 勤勞者에 대하여 使用者가 一方的으로 變更한 就業規則의 內容을 強要할 수는 없는 것이다.

따라서 就業規則內容을 變更함에 있어 旣存의 勤勞條件의 內容을 勤勞者에게 不利益하게 變更하려면 勤勞者의 同意가 있어야 한다.

즉, 勤勞者 過半數로 組織된 勞動組合이 있는 경우에는 그 組合의 그와 같은 組合이 없는 경우에는 勤勞者의 過半數의 同意를 얻어야 하며 그 同意가 없다면 就業規則의 變更은 效力을 가질 수 없다(勤勞基準法 第95條 第1項).

4. 就業規則과 法令, 團體協約 및 勤勞契約과의 關係

1) 就業規則은 勤勞者의 反對가 없는 限 "就業規則에 의한다"라는 事實인 慣習을 통하여 勤勞關係의 內容이 된다. 그러므로 勤勞者가 就業規則에 定한 各 條項을 具體的으로 알고 있었는가는 問題가 되지 아니한다. 그러나 이러한 勤勞契約의 內容이 모두 有效인 것은 아니다. 왜냐하면 就業規則은 法令과 團體協約에 違反할 수 없고(勤勞基準法 第97條 第1項) 그 限度에서 無效이기 때문이다.

또한 勤勞者는 勤勞者의 代表 또는 勞動組合을 통해 就業規則에 따를 것을 反對할 수 있으며, 個個人의 特約으로 就業規則과 다른 勤勞契約을 締結할 수도 있다함은 契約自由原則에 따라 當然하다.

다만 勤勞基準法 第98條에서 就業規則의 內容基準에 未達하는 勤勞契約上의 特約은 無效이며, 이 부분은 就業規則에 따르도록 하여 勤勞者를 保護하고 있다.

三. 就業規則의 法的 性質

就業規則은 勤勞契約의 共通的인 內容이 되는 것을 豫定한 것이기 때문에 定型化된 勤勞契約 條項의 體系라 理解할 수 있으나 使用者가 一方的으로 定한 것이기 때문에 그 自體를 契約이라 할 수는 없다.

또한, 就業規則은 使用者가 經濟的으로 優越한 地位를 土臺로 하여 勤勞契約을 締結함에 實際上의 便宜를 위해 생긴 것으로 多數의 勤勞契約의 內容을 定型的으로 處理한다는 點에서는 事實上 法規範과 같은 役割을 하지만 法律的으로는 法規範이라 할 수는 없다.

따라서, 就業規則이 각각의 勤勞契約의 內容으로서 受容되기 위해서는 勤勞者의 同意를 必要로 하게 되는 것이다.

就業規則의 法的 性質에 대해서는 學說이 對立되고 있는데 그 理由는 첫째, 勤勞條件의 決定에 대하여 勞動法은 勞使對等의 規則을 理想으로 하고 있으나(勤基法 第93條) 就業規則에 대하여 使用者가 一方的으로 作成·變更할 수 있는 點.

둘째, 國家制定法과 契約만이 法規範으로 當事者를 拘束할 수 있으나, 就業規則은 法規範이 아니면서도 當事者를 事實上 拘束하고 있는 點.

셋째, 就業規則의 作成·變更은 使用者가 一方的으로 決定하고 있으나 勤勞基準法 第98條에 의해 就業規則보다 下向하는 內容의 勤勞契約上의 契約을 無效로 함으로써 就業規則이 勞動保護的 役割을 할 수 있는 規範的 效力을 갖는다는 點에 問題點을 갖고 있다.

就業規則의 法的 性質에 대한 學說은 法規範說과 契約說로 나뉜다.

1. 契約說

1) 純粹한 契約說

就業規則은 請約的 性質을 갖는 勞動契約의 草案이라 하여 市民法的 契約의 自由의 理念下에서 使用者가 一方的으로 決定하는 就業規則을 法規範으로 볼 수는 없다.

勞動法은 使用者와 勤勞者가 對等한 人格體로서 勞動條件을 自由意思에 의한 合意로 決定하여야 할 것이며, 使用者가 一方的으로 만든 就業規則에 勤勞者가 同意한 경우에 비로소 契約의 內容으로 受容될 수 있다고 한다.

就業規則의 內容은 그 全體가 勤勞契約의 共通的 內容이 될 것을 豫

定하고 있으므로 各個의 條項에 대하여 各 勤勞者가 그 意味 內容을 理解하고 具體的 合意를 이끌어 내는 것은 使用者에 비해 劣等한 地位에 있는 勤勞者들에게 있어서는 어려운 일이다.

따라서, 특별히 反對의 意思表示가 없다면 就業規則을 承認한 것으로 볼 수 밖에 없는데 이는 附合契約의 問題點을 그대로 表出하고 있다.

우리 나라에서는 純粹한 契約說을 取하는 學者는 없다.

2) 事實規範說(日最判 昭和 43. 12. 25. 民集 22 第13號 345P.)

就業規則은 使用者가 一方的으로 定한 勤勞條件의 事實上의 基準에 불과하다. 따라서, 就業規則을 法規範으로 본다는 것은 勤勞關係가 勞使의 自由意思를 媒介로 하여 成立하는 것을 前提로 하는 近代法의 基本原理에 反한다. 따라서, 就業規則의 拘束力의 根據를 勤勞者의 合意에서 求하고자 하는 것이다.

이에 대하여는 就業規則의 社會規範으로서의 性格을 認定하고 있기 때문에 社會規範의 根據 내지 妥當性을 當事者의 合意에서 求하고 있는 難點이 있다.

2. 規範說

就業規則은 法規範이라고 解釋하는 立場으로 法令과 같이 拘束力이 있다고 본다(서울 民地判 1974. 8. 30. 宣告 73 가합 6032 判決, 서울高判 1976. 4. 2. 宣告 75 나 2809 判決 參照).

1) 所有權 내지 經營權說

就業規則은 所有權의 行使에 의해 創設된 經營體의 秩序로 그 秩序에 대한 國家의 保障을 法規範의 根據로 보는 것이다.

그러나, 使用者는 生產手段의 所有者로써 工場施設 등의 管理運營權이 있지만 그 때문에 勤勞條件에 대한 使用者의 一方的 決定權이 正當化될 수는 없다.

2) 慣習法說

就業規則은 社會規範으로서의 作用을 하기 때문에 慣習法으로 認定하여온 社會的 法規範이다. 그 根據로는 公共秩序나 善良한 風俗에 反하지 않는 慣習은 法令의 規定에 의하여 認定된 것과 法令에 規定이 없는 事項에 대하여 法律과 同一한 效力을 갖는다는 點에 두고 있다.

그런데, 特定企業에서 就業規則이 처음으로 制定되었거나 또는 旣存의 就業規則이 全面的으로 改正되어 同一性을 喪失하는 경우에는 就業規則의 法規範性을 認定할 수 없다. 왜냐하면, 社會에 現實的으로 存在하고 慣習的으로 認定된 것이 아니기 때문이다.

3) 授權說 또는 法規說

使用者가 作成한 就業規則이 當該 事業場의 勤勞者를 拘束하는 것은 勤勞者의 同意에 의한 契約에 根據하는 것이 아니고 事業場에서의 勞動關係가 開始됨에 따라 就業規則의 拘束力을 받으며, 그 根據로는 勤勞基準法 第98條가 勤勞者保護의 目的에서 就業規則에 관하여 勤勞條件의 最低基準으로서의 法規範的 效力을 認定한 때문이다 라고 한다(심태식 勞動法 法文社 1981. pp. 392~396).

3. 判例의 立場

就業規則이 事實上 法規範의 機能을 하는 現實을 直視하여 理論上으로도 規範性을 承認하고 이를 前提로 하여 法的 規制를 發展시키려 한다(大法院 1977. 7. 26. 宣告 77 다 355 判決).

就業規則은 勤勞基準法이 從屬的 勞動關係의 現實에 立脚하여 實質的으로 不平等한 勤勞者의 立場을 保護, 強化하여 그들의 基本的 生活을 保護 向上시키려는 目的의 一環으로 그 作成을 強制하고 이에 法規範性을 附與한 것이라고 하여 勤勞者의 同意 없이도 規範力을 갖는다는 授權說의 立場을 取하고 있다.

4. 結 論

判例와 授權說에 의하면, 就業規則은 勤勞基準法이 規範力을 附與한 것이므로 勤勞者의 同意 없이 勤勞者를 拘束할 수 있다는 前提에서 出發하여 勤勞者에게 不利한 變更도 勤勞者를 拘束한다는 結論에 빠지게 되므로 結果的으로 勤勞者 保護精神에 어긋나는 結果를 낳게 된다.

따라서, 1989. 3. 26. 勤勞基準法 第95條를 改正하여 不利益 變更時 勤勞者 過半數의 同意를 얻도록 하였으므로 就業規則의 法的性質에 따라 就業規則의 變更에 있어 勤勞者의 同意가 必要하다는 點에 대한 차이는 없게 되었다.

四. 就業規則의 作成·變更과 勤勞者의 同意

1. 就業規則 變更에 관한 學說과 判例

1) 契約說

就業規則을 使用者가 提示하는 契約條件으로서의 請約이라고 보아 이 內容을 變更하는 것도 使用者의 自由이다.

그러나, 使用者의 一方的 作成 變更만으로 勤勞契約에 效力을 미칠수는 없다. 즉, 勤勞者의 同意가 있을 때 비로소 勤勞契約의 內容이 되고 就業規則 自體의 有效, 無效를 論할 必要가 없다.

勤勞者가 不利益 變更에 特別히 異議를 하지 아니하고 일한다면 使用者의 勤勞契約 變更 申請에 대하여 默示的 承認을 한 것으로 되어 就業規則은 個別 勞動契約의 內容이 된다.

그러나, 勤勞者가 變更된 條項에 따르지 않겠다는 뜻을 表明하면 旣存의 就業規則의 效力이 持續된다(石井 照久 勞動法の硏究 pp. 122~125).

2. 規範說

1) 經營權說

就業規則 自體를 法規範으로 보는 純粹 規範說에서는 變更된 不利益

條項도 當然히 法規範으로 勤勞者를 拘束한다.

2) 授權說

適法한 節次를 밟아 일단 法規範으로 成立한 就業規則은 保護法 原理의 참된 實現을 위해 法規範的 效力을 認定받게 된다.

따라서, 最初에 作成된 就業規則이 最低의 勞動條件의 基準으로 承認된 것이고, 그후에 使用者가 一方的으로 改正한 것은 原則的으로 勞動條件의 向上의 方向에서만 許諾된다고 한다.

그러나, 例外的으로 勤勞者集團의 同意가 있는 경우에는 不利益 變更도 可能하다. 즉, 勤勞者團體를 통하여 表明된 意思는 特殊한 경우를 除外하고 勤勞者의 自由로운 意思表示로 보아야 하며 勤勞基準法은 勤勞者의 自由意思를 尊重함을 原則으로 하므로 이때의 不利益 變更은 可能하다고 한다(就業規則의 法的 性質 勞動法學會誌 4호 pp. 24~26).

이에 대하여 使用者는 勞動者를 拘束하는 法規인 就業規則을 一方的으로 作成하는 權限을 認定 받고 있다고 하면서 勤勞者에게 有利한 變更만을 許容하고 不利益 變更에 勤勞者의 同意를 必要로 함은 理論的으로 困難하다는 批判이 可能하다.

3. 一方的 變更을 沮止하기 위한 기타理論

1) 既得權 理論 내지 契約 化體說

既存의 就業規則의 內容을 一種의 既得權으로 把握하여 就業規則의 變更의 경우 從來의 內容이 新規則보다 有利하다면 勤勞者에게 有利한 勤勞條件은 勞動契約의 내용으로 化體되어 있다.

2) 集團的 契約說

勞動條件에 관한 限 就業規則의 作成·變更에 있어 반드시 그 事業場의 勤勞者集團의 同意를 얻어야만 하며 同意가 없다면 그 就業規則의 作成·變更은 無效이다.

이 說은 就業規則의 效力 發生의 要件으로 勤勞者의 同意를 要한다는

點에서 基本的으로 契約說의 立場을 取하지만 일단 成立한 就業規則의 規範的 效力을 認定하는 點에서 法規說을 取하는 折衷的 見解이다.

3) 二分說

就業規則의 性質에 따라 考察하는 方法이다.

就業規則에는 使用者와 勞動者의 合意를 媒介하는 勞動關係를 規律하는 部分(賃金, 勞動時間 등의 協議의 勞動條件)과 使用者가 勞動契約上 갖는 指揮命令權에 의해 作成하여 勞動者에게 告知함으로써 效力이 생기는 部分(就業에 대한 行政準則에 대한 事項)이 있으며 前者에 대해서는 合意에 의한 有利한 個別契約이 認定되나 後者에 대해서는 規律을 緩和시키는 特約이 不可能하다(有泉亨, 勞動基準法 法律學 全集 pp. 191~208).

4. 判例의 立場 "1977. 7. 26. 宣告 77다 355 이래 判例의 傾向"

1) 退職金 規程의 變更에 관한 判例

(1) 「就業規則은 使用者가 企業經營權에 의해 事業場에 있어서의 勤勞者의 服務規律이나 勤勞條件의 基準을 劃一的, 統一的으로 定立하기 위하여 作成하는 것으로써 이는 勤勞基準法이 從屬的 勤勞關係의 現實에 立脚하여 實質的으로 不平等한 勤勞者의 立場을 保護 強化하여 그들의 基本的 生活을 保護 向上시키려는 目的의 一環으로 그 作成을 強制하고 이에 法規範性을 附與한 것.」이라고 하여 勤勞者의 同意없이도 規範力을 가진다는 授權說을 取하면서도,

(2) 「原則的으로 就業規則의 作成 變更權은 使用者에 있다 할 것이나 既存 就業規則의 適用을 받고 있던 勤勞者集團의 集團意思決定方法에 의한 同意를 要한다 할 것이다」라고 하여 勤勞條件의 一方的 變更에는 勤勞者 集團의 同意를 要하는 것으로 하고 있다.

그 根據로서 「勤勞基準法의 保護法으로서의 精神과 既得權保護의 原則 및 勤勞基準法 第3條, 그리고 勤勞基準法 第95條의 勤勞者의 過半數의 意見을 들어야 한다」는 規定을 들고 있다.

(3) 그 同意의 方式도 「勤勞者 過半數로 組織된 勞動組合이 있는 경우에는 勞動組合의 同意, 그와 같은 勞組가 없는 경우에는 勤勞者들의 會議方式에 의한 過半數의 同意」를 要求하며, 그 根據로 개개의 勤勞者의 同意로 족하다고 할 경우에는, ① 就業規則의 變更이란 形式으로 旣存 就業規則에 未達하는 勤勞契約을 締結하여 同法 第98條를 無意味하게 하며 ② 여러 個의 就業規則이 한 個의 事業場에 竝存하게 되고 ③ 集團에 適用되는 法規範의 變更은 集團的 意思에 의한 同意를 얻게 함이 一般 法規範의 變更節次로서도 妥當하다고 한다.

위 判決에 의해 「集團意思決定方法에 의한 同意를 必要로 한다」는 原則이 確立된 以後 法院의 實務와 判決은 大部分 이 判決의 態度를 受容하고 있다.

2) 위 判決에 대한 批判

(1) 理論的 矛盾

大法院 判決은, 勤勞者의 同意가 없어도 勤勞基準法 第94條, 第95條의 節次를 밟으면 規範力을 부여 받아 勤勞者를 拘束할 수 있다는 授權說의 前提에서 出發하여 使用者는 就業規則 變更時 勤勞者에게 不利한 變更이 이루어지더라도 勤勞者를 拘束하는 事態가 發生하자 集團에 適用되는 法規範의 變更은 集團的 意思에 의한 同意를 얻게 함이 一般法規範의 變更節次로서도 妥當하다 하고 있으나, 授權說의 核心은 就業規則이 法規範인 것은 勤勞者의 同意에 두는 것이 아니라 그 同意와는 관계없이 勤勞基準法이 勤勞者保護의 目的으로 規範力을 부여한 것이기 때문이다 라고 하는 데 있는 바, 이는 前後와 矛盾된 主張이라 할 것이다.

大法院의 判決이 授權說에 充實하려면 「使用者는 就業規則의 制定·變更에 의하여 勞動條件을 一方的으로 決定·變更할 수 있고 이것이 勞動者에게 不利益한 것이라 하더라도 團體交涉에 의해 그 解決을 圖謀하지 않는 限 그러한 就業規則의 制定·變更에 의해 勞動契約의 內容도 當然히 變更을 받는다」라는 東京高等裁判所 1952. 8. 31. 判決과 같이 判

示하여야 할 것이다.

(2) 明文規定에 違背

勤勞基準法 第95條에 의하면 「勤勞者의 過半數의 意見을 들어야 한다. 다만 就業規則을 勤勞者에게 不利益하게 變更하는 경우에도 그 同意를 얻어야 한다」라고 되어 있고(1989. 3. 29. 改正), 또 但書 條項에 의해 同意를 얻어야 할 경우라도 會議方式에 의한 勤勞者 過半數의 同意라고는 하지 않고 있다.

但書 條項의 '同意'를 '會議方式에 의한 勤勞者 過半數의 同意'라고 확대 解釋하는 것은 勤勞基準法을 사실상 變更하는 것으로 三權分立의 原理를 正面에서 無視하는 것이며, 또한 國民의 權利義務를 規律하는 法律의 制定은 國民의 代表機關인 國會에 의해 制定·變更되어야 한다는 成文法 中心主義의 우리 法體系를 根本的으로 뒤흔드는 잘못을 범하고 있다.

(3) 就業規則의 變更에 있어 個個人의 同意로 족한다고 할 경우 就業規則의 變更이란 形式으로 既存 就業規則에 未達하는 勤勞契約을 締結하여 同法 第98條를 無意味하게 하며, 또 한 개의 事業場에 여러 개의 就業規則이 竝存하게 된다는 點에 대하여서는, 使用者의 就業規則 變更에 따른 勤勞契約의 變更에 대하여 근로자가 集團的으로 交涉하여 어떤 妥協點이 생기면 就業規則을 承認하는 것이고, 만일 이러한 妥協案이나 애초의 請約에 滿足할 수 없는 勤勞者는 勤勞契約關係에서 脫退할 수 밖에 없을 것이다.

아무런 意思表示 없이 그 事業場에서 계속해서 勤務를 계속한다면 결국 請約에 대한 默示的 承諾으로 보아야 할 것이다.

就業規則의 變更으로 既存의 就業規則은 消滅하게 되므로 한 個의 事業場에 여러 個의 就業規則이 竝存하는 상황은 있을 수 없으며, 또한 既存就業規則에 未達하는 勤勞契約의 締結로 勤勞基準法 第98條를 잠탈한다는 경우에는 그 就業規則의 合理性 與否를 判斷함으로써 問題를 解決하도록 함이 옳지 않을까 한다.

또한, 勤勞基準法 第3條의 趣旨에 따라 團結權, 團體交涉權, 勞動爭議權을 附與하여 勤勞契約締結過程에서 事實上 對等한 힘을 保障하고 使用者의 전횡을 防止하도록 하여야 할 것이다.

3) 停年制規定의 變更에 관한 判例(1978. 9. 12. 宣告 78다 1046 判決)

위 判決은 勤勞者集團의 同意없이 就業規則을 變更하여 停年制를 新設한 경우에 대하여 「從前의 就業規則에 職員의 停年에 대한 아무런 制限規定이 없다고 해서 그 職員인 原告가 그 年齡에 관계없이 無限定 被告組合에서 勤務할 수 있음을 保障한 것이라고는 볼 수 없는 바, 被告組合이 從前 就業規則의 適用을 받던 勤勞者集團의 同意없이 一方的으로 그 就業規則을 變更하여 職員의 停年을 滿55歲로 하고 停年에 달한 때에는 解職하여야 한다는 內容의 規定을 두었으나, 그 停年을 위와 같이 滿55歲까지로 定한 것이 一般 通例에서 벗어난 不合理한 制度라고 볼 수 없는 것이므로 停年의 新設이 勤勞者의 旣存 勤勞條件上의 旣得權을 侵害하는 勤勞條件의 變更이라고 斷定할 수는 없으며, 따라서 被告組合의 위 就業規則 變更에 被告 勤勞組合勤勞者의 過半數의 同意가 없었다고 無效라고 할 수는 없다」라고 判示하여 停年制가 合理的인 制度이므로 就業規則을 變更하여 停年制를 新設한 경우에 이를 有效라고 한다. 참고로 日 最判 昭和 43. 12. 25. 判決을 보면 使用者가 새로운 就業規則의 作成 또는 變更에 의해서 勤勞者의 旣得權을 侵害하고 勤勞者에게 不利益한 勤勞條件을 一方的으로 附課하는 것은 原則的으로 許容될 수 없다고 할 것이지만 勤勞條件의 集合的 處理 특히 그 統一的 내지 劃一的 決定을 原則으로 하는 就業規則의 性質에서 보면 當該 就業規則條項이 合理的인 것인 限 個個의 勤勞者의 同意를 얻지 아니한 것을 理由로 그 適用을 拒否하는 것은 許容되지 아니한다 라고 하여 就業規則의 變更에 대한 判斷基準으로써 合理性을 提示하여 勤勞者의 同意가 就業規則變更의 要件이기는 하지만 그 變更이 合理的인 것이라면 勤勞者의 同意가 없어도 變更의 效力을 認定하고 合理的인 內容이 아니라면

就業規則을 一方的으로 變更할 수 없다고 한다.

위 判決을 使用者側에서 여러 가지 合理的인 理由로 就業規則의 變更을 하였으나 勤勞者側에서 이에 同意하지 아니한 경우, 즉 會社가 合理的인 理由로 會社의 存續을 위하여 就業規則을 變更하였는데 勤勞者側에서 不當하게 同意하기를 拒否할 경우 그 變更에 勤勞者 個個人의 同意가 必要하다는 理論을 끝까지 固守함으로써 오는 會社와 근로자의 破綻을 피하기 위해 契約의 一般理論인 承諾의 要件을 緩和한 判決이다.

우리 나라의 1978. 9. 12. 78다 1046判決과 日最判 昭和 43. 12. 25. 判決은 就業規則의 效力을 合理性理論에 따라 判斷하였다는 點에서 類似性이 있다고 할 것이다.

4) 우리 나라 判例의 立場을 整理해 보면

기존의 就業規則을 勤勞者에게 不利益하게 變更하는 경우에는 勤勞者의 同意를 얻지 못하면 새로운 就業規則을 無效로 하며 旣存의 就業規則 內容이 계속하여 效力이 維持되는 것으로 보고, 새로운 就業規則을 作成함에 있어서는 勤勞者의 同意를 얻지 못한 경우라 해도 그것이 合理的이라면 새로 作成된 就業規則의 效力을 認定하고 있다고 볼 것이다.

2. 就業規則의 變更과 勤勞者의 同意

1) 勤勞契約 條件을 變更시키는 內容의 就業規則의 變更에는 勤勞者의 同意가 必要하다.

(1) 契約說의 立場에서는,

勤勞契約의 變更에는 契約 一般의 原則에 따라 變更에 관한 請約과 이에 대한 相對方의 承諾이 있어야 한다고 하여 就業規則이 勤勞契約의 內容이라면 使用者의 就業規則 變更形式을 통한 請約에 대하여 勤勞者의 同意라는 承諾의 意思表示가 合致하여야 有效하게 變更된 契約으로 勤勞者를 拘束할 수 있다고 한다.

(2) 授權說의 立場에서는,

使用者가 一方的으로 就業規則을 變更할 수 있다고 하여도 勤勞基準法 第3條「勤勞條件은 勤勞者와 使用者가 對等한 地位에서 自由意思에 의해 決定되어야 한다」라는 規定趣旨를 살리기 위해, 勤勞者가 個別的으로 使用者와 交涉하는 것이 對等한 地位를 保障해 줄 수 없으므로, 同法 第95條는 使用者가 勤勞契約을 變更할 時 勞動組合이나 勤勞者의 過半數의 意見을 듣고 특히 不利益 變更時에는 그 同意를 얻도록 節次的 保障을 하고 있는 것이다.

따라서, 勤勞者側은 使用者가 第95條의 節次를 밟아야만 하는 것을 利用하여 團體交涉 등 協商을 通하여 有利한 契約締結에 이를 수 있도록 努力할 機會를 保障받고 있다(日 昭和 40. 5. 31. 후쿠오까 地·判의 判決도 「就業規則의 制定變更 內容 決定을 使用者가 원하는 대로 放置할 때에는 劣惡한 勞動條件과 苛酷한 制裁가 賦課될 危險이 있기 때문에 勞動者에게 意見을 表明할 機會를 주어 使用者의 專橫을 防止하고 同時에 勞動者의 勞動條件에 대한 關心을 높여 勞組運動을 通해 勞動條件의 協約化를 指向하는데 있다」고 判示하고 있다).

2) 同意의 方式

勤勞基準法 第95條 1項에서 使用者는 就業規則의 作成·變更에 관하여 當該 事業場에 勤勞者의 過半數로 組織된 勞動組合이 있는 경우에는 그 勞動組合, 勤勞者의 過半數로 組織된 勞動組合이 없는 경우에는 勤勞者의 過半數의 意見을 들어야 한다.

다만, 就業規則을 勤勞者에게 不利益하게 變更하는 경우에는 그 同意를 얻어야 한다(1983. 3. 29. 本項 改正)라고 하고 있다.

(1) 勞動組合이 있는 경우

① 就業規則을 作成, 變更함에 있어 數個의 事業場을 單位로 勞動組合 分會가 組織되어 있고, 각 事業場에 傘下 勞動團體가 組織되어 있으면 그 名稱에 不拘하고 當該 事業場 單位勞動團體(勞動者의 過半數 加入)의 意見을 들어야 한다.

② 就業規則을 作成·變更하고자 하는 事業場單位 勞動組合이 組織되어 있지 않고 이를 包含하는 數個의 事業場을 單位로 하는 勞動組合만이 組織되어 있는 경우, 勞動組合의 組織形態에 關係없이 勞動組合이 전혀 없거나 기타 事由로 同意를 할 수 없다면 모르되 그렇지 아니한 경우라면 勞動組合分會(當該 事業場 勤勞者의 過半數加入)의 同意가 우선한다.

③ 한 個 事業場에 2개 以上의 勞組가 있는 경우, 한 組合이 當該 事業場의 勞動者의 過半數로 組織되었다면 그 多數 組合의 同意로 充分하다.

④ 어느 組合도 過半數를 차지하지 못하고 非組合員의 數가 事業場 勞動者의 過半數에 達할 때에는 그 未組織 勞動者의 同意가 있어야 한다.

(2) 勞動組合이 없는 경우

① 勞組가 組織되어 있지 아니한 경우에는, 全體 勤勞者의 多數決에 의해 就業規則 作成·變更에 관한 意見表明의 權限을 갖는 者로 選出된 경우에 限하여 勞動者의 代表로 할 수 있다.

② 勞組도 없고 代表者도 없는 경우에, 判例는 勤勞者의 「會議方式에 의한 過半數」의 同意가 必要하다고 하나 이러한 會議方式에 의한 勤勞者의 過半數는 第95條에 없는 것으로 問題가 있다함은 이미 說明하였다.

따라서, 이 경우에는 個個 勞動者의 同意를 얻어 同意한 勤勞者의 數가 過半數에 이를 때에 勤勞者 過半數의 同意의 要件이 充足되는 것으로 보아야 할 것이다.

勤勞基準法 第3條나 第95條나 集團的交涉을 規定하고 있지만 이는 어디까지나 契約締結이나 變更過程에서의 事實上 協商 主體로 集團을 保障해 주는 것이지 결코 勤勞契約締結이나 變更時 使用者의 相對方, 즉 承諾의 法律上 適格者가 團體여야 한다는 것은 아니다.

1977. 7. 26. 宣告 77다 355 判決의 背景에는 退職金 支給은 勞使의 合意에 의한다 라는 團體協約이 存在하고 있으므로 이에 符合토록 하기 위하여 退職金規定의 變更解釋에 관한 憲法上 法律變更 節次를 無視하고 成文法 中心主義를 뒤흔들면서 까지 無理하게 會議方式에 의한 勤勞者의 過半數의 同意를 必要로 한다고 하고 있으나, 이는 團體協約의 法

理에 따라 解釋하여야 할 것이고 勤勞基準法 第95條만의 法理를 확대 適用해서는 아니될 것이다.

(3) 默示的 同意

使用者側에서 就業規則을 變更하였으나 勤勞者側에서 이에 同意하지 아니하고 그러나 勤勞關係는 계속되어 나간 경우 勤勞者에게 어떤 勤勞契約條件이 適用되어야 할 것인가 하는 問題가 있다.

이에 대하여 ① 勤勞者가 會社를 그만두지 아니하고 ② 또한 아무런 勞使協商을 통한 變更을 시도함이 없이 變更된 就業規則下에서 그대로 계속하여 勤勞關係를 維持하였다면 勤勞者에게 默示的 同意가 있었다고 보는 것이 妥當하다고 본다.(서울高等法院 1991. 11. 27字 判決, 法律新聞 1991. 12. 5字 3面 參照)

3. 就業規則의 變更에 勤勞者의 同意를 얻지 못하였으나 그 內容에 있어서는 合理性이 있는 경우

1) 日最判 昭和 43.12.25 判決에서는 그 以前의 學說判例에는 없던 獨自의 法的 性質論 및 一方的 變更의 效力에 관한 見解를 나타내고 就業規則의 一方的 變更에 의해 設定된 滿55歲 停年制의 效力이 以前부터의 從業員에 미치는 것을 肯定했다.

우선 法的 性質論으로서는 勤勞條件을 定型的으로 定한 就業規則에는 勤勞條件은 就業規則에 의한다 라는 事實인 慣習이 成立하고 있는 것이므로 法的 規範性이 認定되기에 이른 것이고, 여기에서도 適用된다고 하고 있으며, 그리고 一方的 變更에 관해서는 새로운 就業規則의 作成 또는 變更에 의해 旣得의 權利를 剝奪하고 勤勞者에게 不利益한 勤勞條件을 課하는 것은 原則的으로 許容되지 않는다 할 것이나, 勤勞條件의 劃一的 統一的 決定을 基本方針으로 하는 就業規則의 性質에 비추어 當該就業規則 條項이 合理的인 것인 限, 個個 勤勞者의 同意가 없음을 理由로 그 適用을 拒否할 수는 없다고 한다.

이는 會社가 合理的인 이유로 會社의 存續을 위해 就業規則을 變更하

였으나, 勤勞者가 不當하게 同意하기를 拒否할 경우 그 變更에 勤勞者 個個人의 同意가 必要하다는 理論을 끝까지 固守함으로써 오는 會社와 勤勞者 雙方의 破綻을 피하기 위하여 契約의 一般理論인 承諾의 要件을 緩和한 判決이며 그 緩和를 뒷받침하는 理論的 根據로서 默示的 合意의 要件을 내세우고 있는 것이다.

또 札幌地判 昭和 53. 11. 6. 判決에서는,「就業規則을 變更하여 勞動條件을 勞動者에게 不利益하게 變更하는 것도 그 變更이 合理的이라면 許容될 수 있으나, 賃金, 勞動時間 등 勞動契約上 가장 重要한 勞動條件의 變更에 있어서는, 既存의 就業規則 作成當時 豫見할 수 없었던 여러 事情의 變動이 있었고, 또 그 變動이 客觀的 經濟情勢의 變動등 經營主體의 責任에 돌아가지 않는 事由에 따른 것이어서 從前의 勞動條件을 그대로 維持하는 것이 信義則上 妥當하지 않다고 認定되는 특단의 事情이 없는 限 그 合理性의 存在를 認定할 수 없다」라고 하여 合理性 判斷의 基準을 提示하고 있다.

5. 結

1. 大判 1977. 7. 26. 宣告 77다 355 判決의 가장 根本的인 背景은 그 事案이 被告와 勞動組合間에 團體協約이 締結되어 있었고, 同 團體協約 第44條에 退職하는 組合員에게 勞使合意下에 定한 基準에 따라 退職金을 支給한다 라고 規定되어 있었으므로 이에 따라 制定된 退職金規定을 改正함에 있어서도 勞使間의 合意를 거쳐야 할 것이고 이를 거치지 아니한 退職金規定의 變更은 勞動組合法 第36條(① 團體協約에 定한 勤勞條件 기타 勤勞者의 대우에 관한 基準에 違反하는 就業規則 또는 勤勞契約의 部分은 無效이다. ② 第1項의 경우 無效로 된 部分은 團體協約에서 定한 基準에 의한다. 勤勞契約에 規定되지 아니한 事項에 대해서도 또한 같다)의 規定에 따라 無效가 된다고 보아야 할 것이라는 點에 있는 바, 위 大法院 判決의 前提는 결국 團體協約이 存在하고 그 團體協約의 當事者는 個個 勤勞者가

아니고 勞動組合團體이므로 就業規則 變更을 勤勞者 個個人의 同意로 할 경우 이러한 團體協約에 違背되는 것을 피하기 위하여 勞動組合 또는 集團同意를 要하는 것으로 解釋하고 있다. 그러나 이는 團體協約의 法理만으로 충분히 同一한 結論에 到達할 수 있는 것이며, 就業規則 變更에 集團方式의 同意가 있어야 한다는 式의 無理한 接近은 피해야 만 할 것이다.

就業規則의 不利益變更에 있어서는 就業規則의 本質에 대한 契約說, 法規範說의 見解 對立을 떠나 勤勞基準法 第95條 1項 但書에 의해 또한, 勤勞基準法은 勤勞者의 自由意思를 尊重하는 것을 原則으로 삼고 있으므로 勤勞者의 同意가 必要하다는 데는 異議를 提起할 수 없다.

다만, 그 同意의 方式에 있어서 判例는 勤勞者過半數로 組織된 勞動組合, 그러한 勞動組合이 없는 경우에는 勤勞者들의 集團的 意思에 의한 同意로 把握하고 있으나 勤勞者들의 集團的 意思에 의한 同意보다는 法文에 充實하게 勤勞者 個個人의 同意를 받아 그에 同意한 勤勞者가 過半數에 達하였을 때 勤勞者 過半數의 同意가 成立하였다고 봄이 簡明한 解釋이 아닐까 한다.

勤勞者 個個人의 同意를 받을 때 事實上 勤勞者들이 使用者에 비해 劣等한 地位에 있으므로 就業規則의 制定 變更內容決定에 있어 劣惡한 勞動條件과 苛酷한 制裁가 賦課될 危險이 存在하나 이런 點들은 勤勞者에게 勤勞基準法 第3條의 趣旨에 따라 團結權, 團體交涉權, 勞動爭議權 등을 附與하여 勤勞契約締結過程에서 事實上의 對等한 힘을 保障하도록 하여 勞動者에게 意見을 表明할 機會를 주고 使用者의 專橫을 防止함과 同時에 勤勞者의 勞動條件에 대한 關心을 높여 勞組運動을 通해 勞動條件의 協約化를 指向해야 할 것이며, 集團方式의 同意라는 無理한 解釋을 통해 解決할 수는 없을 것이다.

2. 就業規則의 勤勞者에게 有利한 變更

勤勞基準法은 勤勞者의 基本的 生活을 保障, 向上시키며, 均衡있는 國

民經濟의 發展을 기함을 目的으로 하는 바, 勤勞者에게 有利하게 就業規則을 變更하는 경우 勤勞者들이 이에 反對할 理由는 없을 것이다.

따라서, 就業規則의 法規範性을 認定하여 勤勞者의 同意가 없다해도 使用者가 一方的으로 作成한 就業規則은 有效한 것으로 取扱하여야 할 것이다.

勤勞基準法이 就業規則을 承認하고 一定한 規制를 加하고 있는 趣旨는 勤勞條件을 明確하게 함으로써 近代的인 勞使關係를 形成하며, 從屬的 勞動關係의 現實에 立脚하여 實質的으로 使用者에 비해 劣等한 地位에 있는 勤勞者의 立場을 保護 強化하여 그들의 基本的 生活을 保護 向上시키며 勤勞者의 生存權을 具體的으로 保障함에 있다면 勤勞者에게 有利한 勤勞條件(就業規則)의 變更에 必要以上의 法的 規制를 加할 必要는 없고, 勤勞者의 同意를 얻도록 하는 번거로운 節次 없이도 效力을 發할 수 있도록 함이 妥當할 것이다.

이러한 點에 있어서는 授權說이 妥當하다 할 것이다.

3. 就業規則의 새로운 作成에 있어서의 勤勞者에 대한 不利益判斷 就業規則의 不利益 變更에 있어서는 勤勞者의 同意가 없는 새로운 就業規則을 無效로 한다 해도 旣存의 就業規則의 效力이 持續되어 나가기 때문에 使用者와 勤勞者 사이의 勤勞契約은 存續될 수 있으나, 새로이 就業規則을 만들어 감에 있어서는 勤勞者의 同意가 없다하여 새로 作成한 就業規則을 無效로 한다면 旣存의 就業規則이 없어서 從前의 勤勞契約 自體가 內容을 確定할 수 없는 狀態에 빠지게 된다.

그렇다면, 內容을 確定할 수 없는 契約은 無效로 되고 勤勞契約 自體가 無效化 될 우려가 있다.

勤勞者를 保護하기 위해 就業規則의 作成에 勤勞者의 同意를 要하도록 한 것이 도리어 毒素條項으로 變하여 勤勞者가 勤勞契約에서 脫落될 危險에 直面하게 된다.

따라서, 이 경우에는 그 就業規則이 合理的인가를 判斷하여 就業規則

에 合理性이 있음에도 불구하고 勤勞者가 不當하게 就業規則에 同意를 하지 아니하는 경우에는 비록 就業規則 作成에 勤勞者의 同意가 없다해도 그 就業規則의 效力을 認定해야만 한다는 것이 日 昭和 43. 12. 125 判決의 趣旨일 것이다.

就業規則의 作成에 있어 勤勞者의 同意를 얻지 못하여 그 就業規則이 無效가 되고 이에 따라 勤勞者들이 勤勞關係에서 脫退하게 된다면 勤勞基準法의 勤勞者 保護精神에 反하게 되므로 就業規則의 新設의 경우에 있어서는 그 就業規則이 一般 通例에서 벗어난 不合理하거나 旣存의 旣得權을 侵害하지 아니한다면 그 就業規則을 無效로 할 것은 아니다.

「大法院 1978. 9. 12. 申告 78 다 1046의 判決에서도 職員의 停年에 아무 制限規定이 없다고 無限定 被告組合에서 勤務할 수 있음을 保障한 것이라고는 볼 수 없는 바, 停年을 滿55歲 까지로 定한 것이 不合理한 制度라고 볼 수 없고, 停年制의 新設이 旣得權을 侵害하는 勤勞條件이라 斷定할 수 없으며」라고 하여 合理性理論에 接近하여 가고 있음을 볼 수 있다.

4. 大法院 判例의 立場을 整理해 보면, 原則的으로 就業規則의 作成變更權을 使用者가 갖고 있으며, 就業規則의 變更에 대하여 勤勞者의 同意를 받아야 하고 그 同意를 얻지 못한 경우 就業規則變更의 效力을 認定하지 아니하고 旣存의 就業規則의 效力이 持續되고 있다고 보며(1977. 7. 26. 宣告 77다 355 判決), 就業規則의 새로운 作成에 있어서는 勤勞者의 同意가 없다해도 그 새로이 作成한 就業規則이 合理的이라면 그 새로운 就業規則의 效力을 認定하여 合理性理論에 接近하고 있다(1978. 9. 12. 宣告 78다 1046).

이를 1991. 4. 9. 宣告 90다 16245 判決과 比較해 보면, 「就業規則이 勤勞者에게 不利益하게 變更된 경우에는 그 同意를 얻어야 하고 그 同意를 얻지 못한 경우에는 勤勞者에게 不利益하게 變更된 部分은 無效라고 할 것」이라고 하여 1977. 7. 26. 宣告 77다 355 判決과 合致하고 있으며,

또한 「애초에 就業規則을 作成함에 있어 勤勞者의 同意를 얻지 아니하였다 하더라도 그 就業規則의 內容이 勤勞基準法에 違反하지 않는 限 그 就業規則이 全部 無效가 되는 것은 아니다」라고 하여 1978. 9. 12. 宣告 78 다 1046 判決과 合致하고 있다.

더욱 「停年 規則은—諸般 與件에 따라 合理的인 基準을 둔다면 같은 事業場內에서도 職級 또는 職責에 따라 差異가 있을 수 있고—이를 法律上 無效라 할 수 없다」라고 하여 合理性理論에 따른 느낌을 주고 있다.

내용상, 1991. 4. 9. 宣告 90 다 16245 判決은 旣存의 大法院 判決에 대하여 判例를 變更한 것으로 볼 수는 없다. 그러나 變更된 就業規則의 有·無效의 判斷은 合理性을 基準으로 하여야 하고 大法院 判決도 그런 方向으로 바뀌어야 하며, 勤勞者의 同意에 있어 반드시 集團的意思表示라는 方法만을 고집하여서는 아니될 것이다.

· 硏究日時 : 1991. 7. 10(水) 07 : 30~09 : 00
· 硏究場所 : 辯護士會 瑞草別館 5層會議室
· 發表會員 : 崔明圭 辯護士
· 參席會員 : 金光年, 金寅德, 裵今子, 元世權, 柳鉉錫, 李載厚, 李海鎭, 林鍾吉, 任統一, 張慶贊, 鄭東潤, 朱大珍, 崔德彬, 韓晳薰, 黃桂龍.